Doctrine

# TAR Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2024, n. 17

TAR
Decreto presidenziale
7 febbraio 2023
>
**TAR**
**Sentenza**
**2 gennaio 2024**

**Sul provvedimento**

Citazione : TAR Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2024, n. 17

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo

Numero : 17

Data del deposito : 2 gennaio 2024

Fonte ufficiale : Scarica documento

**Testo completo**

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00017/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00850/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 850 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Buffa e Marco Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniele Buffa in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore* non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego n. -OMISSIS-, notificato ai suddetti ricorrenti in data 30.01.2019, mediante il quale il Comune di Palermo ha denegato il titolo abilitativo in sanatoria di cui all'istanza di condono edilizio prot. n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quello sopra indicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2023 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La vicenda fattuale posta a fondamento del gravame in epigrafe può essere così sintetizzata:

- in data 1 aprile1986 il sig. -OMISSIS- ha presentato istanza di condono avente ad oggetto un capannone realizzato in difetto di titolo edilizio in Palermo alla via -OMISSIS-su un suolo di sua proprietà;

- in data 8 aprile 2014 la sig.ra -OMISSIS-, n.q. di coerede del sig. -OMISSIS-, ha presentato al Comune di Palermo perizia giurata ai sensi dell'art. 17 della L.R. Sicilia n.

4/2003, successivamente integrata in data 12 dicembre 2014 con ulteriore perizia;

- il Comune di Palermo ha emesso la nota prot. n. -OMISSIS- con cui ha attestato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, L.R. n. 4/2003, che la perizia giurata così presentata sostituisce ad ogni effetto di legge la concessione in sanatoria e esso Comune ha rilasciato il certificato di agibilità n.-OMISSIS-;

- a seguito di successivi accertamenti, il Comune di Palermo ha verificato: il mancato ripristino delle opere abusive ulteriori dichiarate in perizia; la diversa destinazione urbanistica del capannone (industriale e non commerciale, come dichiarato in perizia); l'esistenza di un frazionamento catastale non dichiarato in sede di condono;

- all'esito di ulteriore sopralluogo e previa comunicazione di avvio del procedimento, il Comune di Palermo, con provvedimento del-OMISSIS-, ha annullato in autotutela la concessione edilizia formatasi secondo il " *meccanismo* " assentivo previsto dall'art. 17 della L.R. n. 4/2003;

- all'esito di " *un supplemento di istruttoria* " (così il Comune nel provvedimento impugnato), l'amministrazione comunale ha accertato, tra l'altro, che le opere abusive ricadono nell'ambito della fascia di rispetto delle aree boscate all'interno di un'area con vincolo idrogeologico;

- dagli accertamenti del 2016 è in particolare emerso che l'immobile abusivo è stato oggetto di una pluralità di interventi edilizi tali da modificarne la struttura rispetto a quella emergente dalla originaria istanza di condono;

- in ragione di ciò, con il provvedimento impugnato in epigrafe, il Comune di Palermo ha diniegato l'istanza condonistica proposta, notificandola ai comproprietari, individuati in -OMISSIS-, -OMISSIS-, eredi del dante causa di -OMISSIS-;

2. Avverso il provvedimento impugnato parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

" *I VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 L.R. SICILIA 16.4.2003 N. 4; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.32, COMMA 25, DEL D.L. 30.09.2003 N. 269, CONVERTITO CON LA LEGGE 24 NOV. 2003 N. 326; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31, L. N. 47/1985; ECCESSO DI POTERE; CARENZA DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO MANIFESTO; SVIAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, ART. 3; DIFETTO ED ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE.* ".

In sostanza, i ricorrenti ritengono che l'amministrazione abbia consumato il potere di provvedere per effetto dello spirare del termine previsto dall'art. 17, comma 3, della L.R. n. 4/2003.

" *II VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 L.R. SICILIA 16.4.2003 N. 4; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.32, COMMA 25, DEL D.L. 30.09.2003 N. 269, CONVERTITO CON LA LEGGE 24 NOV. 2003 N. 326; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31, L. N. 47/1985; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COST.; ECCESSO DI POTERE; CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI DINIEGO; CARENZA DI ISTRUTTORIA; CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI ATTI E PROVVEDIMENTI; TRAVISAMENTO MANIFESTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, ART. 3; DIFETTO ED ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE.* ".

Con detto motivo i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato nella parte in cui esso contesta ai medesimi l'esecuzione di ulteriori opere abusive che, a loro dire, sono state in parte già demolite e, in ogni caso, potrebbero essere oggetto di demolizione con conseguente ripristino dello stato dell'immobile al tempo della presentazione dell'istanza di condono.

Inoltre essi contestano il generico riferimento contenuto nel provvedimento di diniego alla esistenza del vincolo paesaggistico, senza l'enunciazione delle ragioni di incompatibilità con il vincolo medesimo.

" *III VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COST; VIOLAZIONE DEI CANONI DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE; CARENZA ED ERRONEITA' DI ISTRUTTORIA; TRAVISAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, ART. 3; DIFETTO ED ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.* ".

I ricorrenti ritornano sulle " *ulteriori opere abusive* " e sulla loro inidoneità a supportare il provvedimento impugnato.

" *IV VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/1990, ARTT. 1 e 2; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 L.R. SICILIA 16.4.2003 N. 4; VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO.* ".

Con l'ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la lesione del proprio affidamento derivante dal lungo lasso di tempo trascorso tra la proposizione dell'istanza di condono e la sua definizione.

3. All'esito dell'udienza di smaltimento del 11 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

5. Anzitutto è infondato il primo motivo di ricorso.

5.1 Invero, parte ricorrente assume che il diniego di condono impugnato con il gravame in esame sia intervenuto in carenza di potere per l'inutile decorso dei termini previsti dall'art. 17, comma 3, della L.R. del 16 aprile 2003, n. 4, che prevede espressamente che: " *Gli uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche successivamente all'avvenuto tacito accoglimento delle istanze di sanatoria e comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro quindici giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente assentita. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e481 del codice penale.* ".

5.2 In punto di fatto, il Collegio rileva che la concessione edilizia in sanatoria formatasi *per UM* ai sensi della richiamata normativa regionale è stata espressamente annullata dal Comune di Palermo con il provvedimento del -OMISSIS-, che, a sua volta, è stato impugnato dagli odierni ricorrenti innanzi al Tar Palermo con ricorso n.r.g. -OMISSIS-, dichiarato perento con D.P. del -OMISSIS-

5.3 La perenzione del prefato ricorso determina il consolidamento degli effetti del provvedimento di annullamento del condono formatosi sulla base del meccanismo effettuale a formazione progressiva previsto dalla L.R. n. 4/2003 e, pertanto, la censura proposta avverso l'espresso diniego di sanatoria all'esame è destituita di fondamento.

6. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione ed essi sono del pari infondati.

6.1 In sintesi, entrambi i motivi in scrutinio censurano il provvedimento gravato nella parte in cui esso motiva il diniego di condono per l'esecuzione di " *ulteriori* " opere in pendenza dell'istanza condonistica.

6.2 Va in premessa osservato che nel provvedimento di diniego il Comune di Palermo dà atto delle seguenti, circostanziate evidenze fattuali:

- discrasia tra la destinazione d'uso dichiarata nell'istanza medesima (" *industriale* ") con quella dichiarata nelle perizie del 2014 (" *commerciale* ");

- frazionamento, non oggetto di condono, dell'originaria unità immobiliare in due unità, di cui l'una " *difforme dallo stato dei luoghi* " e l'altra con variazione della destinazione urbanistica da D8 a C2, in difetto di titolo autorizzatorio.

Le prefate opere abusive hanno comportato l'annullamento in autotutela del titolo in sanatoria formatosi *per UM* , divenuto definitivo a seguito della perenzione del ricorso nrg -OMISSIS-.

Inoltre, l'amministrazione deduce ancora che:

- le opere abusive ricadono all'interno della fascia di rispetto delle aree boscate artificiali, in area a rischio idrogeologico;

- la Soprintendenza competente ha rilevato di non aver rilasciato alcun nulla-osta per l'esecuzione degli interventi edilizi in esame, che avrebbero necessitato di un titolo espresso, non potendo operare l'istituto del silenzio assenso;

- sono state rilevate incongruenze tra le superfici rilevate e quelle dichiarate.

In sintesi, il Comune di Palermo rileva come sia " *documentalmente provato* " che, successivamente alla presentazione dell'istanza di condono, sull'immobile sia stata eseguita ulteriore attività edilizia " *... che ha variato la configurazione strutturale, plano-volumetrica e funzionale degli immobili in condono al punto che non può determinarsi alcuna distinzione tra le porzioni in sanatoria e le ultertiori opere abusive, impedendo di fatto il conseguimento del condono edilizio; - la discordanza delle superfici dichiarate nei modelli ministeriali e nell'atto di notorietà e quelle asseverate nella perizia giurata dell'Ing. -OMISSIS-) lascia presupporre che la dichiarazione dell'atto di notorietà non sia corrispondente al vero; - nella stessa perizia risultano riportati estremi di richiesta Nulla Osta alla Soprintendenza e di avvenuto silenzio-assenso riferiti ad altra ditta e pertanto anche questi non corrispondenti al vero; ...* ".

6.3 A seguito di tali circostanziate evidenze, i ricorrenti si limitano ad una contestazione generica, ritenendo che il Comune abbia fatto riferimento a " *non meglio precisate "ulteriori opere abusive"* ".

6.3.1 Sul punto è anzitutto manifestamente infondata la censura di difetto di motivazione veicolata con il secondo motivo di ricorso; come visto, il provvedimento

impugnato dettaglia in fatto la situazione dell'immobile con un accertamento tecnico puntuale che sfugge ai rilievi generici di parte ricorrente.

6.3.2 Peraltro, i ricorrenti si riferiscono alla necessità che il Comune provi l'esecuzione delle " *ulteriori opere* " che esso assume siano state eseguite da parte dei ricorrenti medesimi.

Ora, anche in disparte dalla già rilevata sufficienza e congruità della motivazione già *ex se* idonea a supportare una pronuncia di rigetto del proposto ricorso, si rileva come in giurisprudenza sia ricorrente e condivisibile l'affermazione secondo cui: " *L'onere della prova sulla ricorrenza dei presupposti per la condonabilità delle opere grava sulla parte istante. Infatti, nel caso di domande di condono edilizio ricade sull'istante l'onere della prova dell'esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primis, la data dell'abuso e, nel caso di specie, l'effettivo intervenuto cambio di destinazione d'uso e la sua data. Solo il privato può, infatti, fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'abuso; mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio; lo stesso dicasi in ordine alla necessarietà della prova dell'entità e della destinazione d'uso della preesistenza legittimamente assentita.* " (Cons. Stato Sez. VII, 29/09/2023, n. 8594; Cons. Stato Sez. VII, 17/08/2023, n. 7804; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, n. 488/2019).

Agli atti non è presente neanche un principio di prova offerto da parte dei ricorrenti circa la possibile condonabilità delle opere, se non un certificato di esecuzione di interventi demolitori puntualmente contestato dal Comune di Palermo nel provvedimento impugnato

6.4 Del pari destituita di fondamento è la censura del provvedimento impugnato relativa alla asserita mancata valutazione da parte del Comune di Palermo della possibilità di condonare gli abusi oggetto dell'istanza originaria, con " *stralcio* " degli abusi ulteriori commessi in pendenza del procedimento di condono.

6.4.1 Invero, la condivisibile giurisprudenza ha affermato sul punto che: " *In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (quand'anche riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.* " (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sentenza del 7 aprile 2023, nr. 3599).

Peraltro, la medesima giurisprudenza ha condivisibilmente precisato che: " *La valutazione dell'abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l'amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.* " (ex pluris: Cons. Stato Sez. VII, 20/04/2023, n. 4029; e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. VI, 30/06/2021, n. 4919 Cons. Stato Sez. VI, 30/06/2020, n. 4170 Cons. Stato Sez. VI, 12/03/2020, n. 1783).

6.4.2 Va inoltre osservato che il Comune ha accertato la mancata riduzione in pristino degli abusi commessi in pendenza dell'istanza di condono e gli abusi in parola hanno determinato una radicale modificazione della destinazione d'uso dell'immobile, tale da non consentire neanche sul piano della realtà materiale una scissione tra abusi oggetto dell'istanza condonistica ed abusi ulteriori commessi in pendenza della stessa.

Pertanto, la censura in esame appare destituita di fondamento anche in fatto.

6.5 Alla luce delle superiori considerazioni il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.

7. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso.

7.1 Invero, non è predicabile alcun affidamento legittimo in capo ai ricorrenti derivante dal mero lasso di tempo trascorso tra l'istanza di condono ed il suo rigetto.

Sul punto, l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio non intende discostarsi, è compendiabile nella seguente affermazione: " *A fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell'Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati. Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'opera abusiva sulla*

*regolarizzazione di fatto di quest'ultima.* ” ( *ex pluris* : T.A.R. Sicilia Catania Sez. V, 16/08/2023, n. 2532; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 04/07/2023, n. 2228).

8. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e meritevole di rigetto.

9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione del Comune di Palermo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Dario Aragno, Referendario

Guido Gabriele, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Guido Gabriele Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO